

1500597-64.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... de que no local estava ocorrendo tráfico de drogas, e já é um ponto de venda de drogas conhecido. Na data dos fatos foram com viatura descaracterizada e ficaram observando por uns vinte minutos. Viram o réu em atitude de tráfico. Pessoas se aproximavam dele e ele ia até um carro próximo, e pegava a droga. Ele foi detido e confessou que estava no tráfico de drogas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500597-64.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000481

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2080653/2022 - 04º D.P.

DIADEMA, 2080653 - 04º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jeferson Aparecido Santos

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

JEFERSON APARECIDO SANTOS, qualificado às fls. 04 e 08/09, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 23 de março de 2022, por volta das 15h00, na Rua Botocudos, altura do nº 10, bairro do Serraria, nesta cidade e comarca de Diadema, trazia com ele e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 48 embalagens contendo 20,77g da droga cocaína, 27 embalagens contendo 15,32g da mesma droga, na forma de crack, e 41 embalagens contendo 66,00g da droga maconha, conforme auto de apreensão e exibição de fls. 12/13 e laudo de constatação provisória de fls. 18/20, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.33/36), o réu foi notificado e citado (fls.74 e 97/98), e apresentou defesa preliminar as fls.79/81, através do Defensor Público nomeado. Não sendo hipótese de arquivamento, a denúncia foi recebida em 11/05/2022 (fl.83).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas tempestivamente e interrogado o acusado ao final, encerrando-se a instrução processual sem requerimento de diligências, seguindo-se com os debates orais (mídia digital).

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência da ação por provadas autorias e materialidade delitivas. Pleiteou a fixação das penas base acima do mínimo diante da grande quantidade e nocividade da droga cocaína, em que pese a confissão do réu, que não deve preponderar sobre sua multirreincidência, discordando da redução da pena e de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos, fixando-se regime prisional fechado, sem possibilidade de recurso em liberdade, além da perda do dinheiro.

Já o d. Defensor Público reiterou seu pedido de absolvição ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base seja fixada no mínimo legal, compensando-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, reduzindo a pena ainda que em patamar menor, com sua substituição com fulcro no art. 44 do CP, fixando-se regime mais brando, e possibilidade do acusado recorrer em liberdade, até pela detração penal.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição e apreensão de fls.12/13, nos laudos de constatação e no definitivo (respectivamente às fls.18/20 e 101/103), ambos positivos para as drogas cocaína e maconha.

A autoria é inconteste não só com fulcro na prova amealhada extrajudicialmente, como na colhida sob o manto do contraditório que corrobora àquela e a qual passo a expor.

Segundo narrativas administrativas dos policiais (fls.02/03), conduziram preso o indiciado Jeferson Aparecido dos Santos, uma vez que em diligências visando dar cumprimento a Operação ABC-D mais Seguro, lograram abordá-lo no local dos fatos, na prática de tráfico de entorpecentes. Observado o local por alguns minutos e notaram a atuação do indiciado, que parado na esquina da rua, era abordado por indivíduos desconhecidos, recebia valores e entregava algo que suspeitaram ser droga. Viram também que o indiciado retirava a droga de uma pochete de cor preta que estava embaixo da roda de um veículo estacionado na via pública, em estado de abandono. Abordaram o indiciado e ouviram dele a confissão que estava traficando, e apontou com certeza o local onde escondia a droga.

Sob o crivo do contraditório o policial Rafael dos Reis reiterou que na semana da prisão do réu receberam denúncias de que no local estava ocorrendo tráfico de drogas, e já é um ponto de venda de drogas conhecido. Na data dos fatos foram com viatura descaracterizada e ficaram observando por uns vinte minutos. Viram o réu em atitude de tráfico. Pessoas se aproximavam dele e ele ia até um carro próximo, e pegava a droga. Ele foi detido e confessou que estava no tráfico de drogas, indicando onde elas estavam, na roda do carro. Tinha maconha, crack e cocaína na pochete, e aproximadamente quarenta reais em dinheiro trocado com o acusado. Reconhece o réu e foi a primeira vez que o viu no local. Viu o réu vender droga para umas cinco pessoas.

Em solo judicial o policial Moacir Teixeira confirmou que estavam em ronda por Diadema e sabiam que o local é um ponto de venda de entorpecentes. Pararam a viatura

descaracterizada e ficaram observando. Viram o réu vendendo entorpecente, pessoas iam até ele, davam algo, ele ia atrás do carro, pegava uma pochete preta, voltava para a pessoa, entregava algo, e a pessoa ia embora. Isso ocorreu algumas vezes. O abordaram e disseram o que viram. Ele confessou o tráfico e os mostrou o pneu traseiro do carro onde estava uma pochete preta com as drogas e com o réu o dinheiro de vendas que viu que ele fez.

O réu, em solo policial (fl.04), alegou ser usuário de drogas, e tinha dívidas de drogas para pagar. Como não tinha dinheiro, resolveu trabalhar para o tráfico para conseguir dinheiro e pagar suas dívidas, até porque temia pela sua vida. Passou então a traficar, permanecendo no local o dia todo das 08H00 até as 19H00. Recebia 10% do valor arrecadado com a venda de drogas. Vendia cada invólucro com maconha a R\$ 10,00, cada invólucro com cocaína pelo preço de R\$ 5,00 e o de crack pelo valor de R\$ 5,00 cada. Afirma não estar arrependido de sua atitude, porque realmente precisava do dinheiro. Na tarde de hoje foi preso por policiais desta Unidade quando estava vendendo drogas na rua dos Botocudos, e trazido a esta Unidade Policial. Não tem como informar para quem trabalha pois não sabe dizer.

Em juízo o acusado confirmou estar com as drogas para vender e estava com o dinheiro proveniente da venda de drogas. Foi o primeiro dia de venda, para pagar uma dívida, e já foi condenado antes, por tráfico também. Estudou até a oitava série e trabalhava de ajudante geral com seu tio e de aplicativo da Uber.

Logo, a confissão, que não é prova única, tanto que veio corroborada pelos testemunhos dos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem prova contrária, até porque o réu confirmou que estava mesmo vendendo as drogas, embora alegue ter feito para pagar uma dívida, mas não fez prova disso como lhe competia o ônus dessa prova.

Ainda, não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, que só pode incidir nos casos em que se verifica que o sujeito ativo, de fato, não possuía liberdade de agir, e no caso em tela o réu poderia ter feito qualquer outro tipo de trabalho para ganhar dinheiro e pagar sua alegada dívida, pois como ele mesmo disse, trabalhava de ajudante e com o aplicativo da Uber. Ademais, a ameaça de mal grave deve ser certa e inevitável, o que não ocorreu na presente hipótese, dado que o acusado tinha meio de escapar à coação, e portanto deixa de haver excludente de culpabilidade. Não bastasse isso, o crime em tela não se tratou de um fato isolado e excepcional na vida do agente, nem ocorreu por conta do seu estado de vulnerabilidade, até porque ele possui uma vida voltada para crime/tráfico (vide fls. 26, 29 e 30), sendo mais um motivo a se afastar a excludente de culpabilidade.

O mesmo se aplica à tese de absolvição ante à condição de usuário de drogas do agente, que no presente caso, como visto, não veio provada pela Defesa nem pelo acusado, e não afasta a traficância, uma vez que é comumente sabido que dependentes químicos utilizam o tráfico de entorpecentes como meio de perpetuar o vício, de modo que as condutas coexistem, não se excluem, donde afastado o pedido de desclassificação. Neste sentido: A condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira).

Como visto, os policiais afirmaram que durante a campanha que fizeram, presenciaram o réu, por eles reconhecido, vendendo efetivamente drogas à usuários, uns cinco aproximadamente, estando ele sozinho, parado, na biqueira já conhecida, tanto que abordado, não reagiu e confessou o crime, sendo encontrada a pochete com as drogas na roda de um veículo abandonado, estacionado perto do réu, como os policiais já

haviam visto que era dali que ele retirava os narcóticos para entregar aos compradores depois de receber o numerário correspondente da venda.

Em que pese não haver outra testemunha civil presencial arrolada nos autos: É cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais. A defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos policiais militares, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, conforme Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza das drogas (cocaína e maconha e crack), a quantidade de narcóticos (116 no total), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o dinheiro apreendido, são fatores que reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável. Ainda que se trate de agente que se diz usuário, situações que não se opõe, e sim coexistem.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências dos delitos, assim como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (116 no total) o que reputo excessivo, às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do condenado.

Em segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea a ser compensada com a agravante da reincidência demonstrada a fl. 26 (condenação por tráfico na 26ª Vara Criminal da Barra Funda), que por envolver a personalidade do agente, é igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal (STJ, Resp n. 1.154.752/RS, 3ª Seção, DJE 4.9.2012). E me valendo da agravante da reincidência baseada na condenação definitiva por furto junto à 1ª Vara Criminal de Diadema (vide fl. 30), agravo a pena em 1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão mais 680 dias-multa. Nesse sentido, vide recente decisão do e. STJ a respeito: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, inciso I do CP, sendo admissível sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade - STJ - Resp 1.931.145. Grifei.

Em terceira fase, não concorrem causas de aumento de pena. Nem o privilégio previsto do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por se tratar de réu multirreincidente, específico inclusive, embora a lei especial assim não o exija, mas a indicar que faz do crime seu meio de vida, inaplicável a ele a benesse, por expressa vedação legal.

Cito jurisprudência neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 - REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/02/2018) grifo nosso.

Incabível a benesse do art. 44 do CP, por ausentes os requisitos objetivo (pena maior que a permitida) e subjetivo, agente não é primário, o que indica que tal benesse não se mostra socialmente recomendável, até por sua multirreincidência. Ademais: "Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos hediondos, punindo o traficante com maior severidade, inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a liberdade provisória e a progressão de regime." (TJAP) RT 772/617.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, considerada a plurirreincidência do réu e a quantidade de pena, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado, bem como a preponderância da natureza e da quantidade da droga, não ficando o juiz obrigado a fixar regime inicial relacionado unicamente com o quantum da pena, podendo optar por um mais gravoso ao observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006. Veja: Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional. (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Custodiado no curso do processo, o Condenado não poderá exercer o direito de recorrer em liberdade, com mais razão ante a pena aplicada após exauriente cognição e diante do necessário resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal, verificada a possibilidade concreta da continuidade de práticas delitivas por reincidente específico, bem como constatada ausência de vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado. Ora: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de quatro meses, e sem direito sequer à progressão de regime.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de "progressão de regime" pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra JEFERSON APARECIDO SANTOS, qualificado às fls. 04 e 08/09, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 e o faço para condená-lo à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 680 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos corrigido à data do pagamento.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está. Sendo ele assistido pela DPE, reconheço suspensa a exigibilidade de custas e despesas processuais, por ora.

Decreto a perda de bem e valores apreendidos (fl.12), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06, e determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa,

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados.

Diadema, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA